

1500551-39.2022.8.26.0161

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... que o réu praticou crime de roubo, majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, na forma consumada. Portanto, de rigor sua condenação.

Passa-se, pois, à dosimetria das penas.

Observado o art. 59 do Código Penal, a presença de maus antecedentes (fls. 55 e 112 - condenação por roubo na 1a. Vara da Barra Funda). Ressalto que o atual entendimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500551-39.2022.8.26.0161 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500551-39.2022.8.26.0161

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2058927/2022 - 02º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

JONATHAN DA SILVA, qualificado indiretamente às fls. 13/23, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal, no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 08h55, na loja de conveniência situada no posto de combustíveis localizado na Avenida Jurubatuba, nº 61, bairro do Canhema, nesta Comarca, atuando previamente ajustado outro indivíduo não identificado, unidos em desígnios e com divisão de tarefas para o fim comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra Auricelia Maria Almeida de Lacerda, subtraiu para eles, dois maços de cigarros e a quantia de R\$ 396,00 em espécie, bens e valores pertencentes ao Posto Petrolegal.

Foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 68/69). A denúncia foi recebida em 07/03/2022 (fl. 68/69). Citado (fls. 87/88), foi apresentada defesa inicial feita por Defensor Público nomeado (fl. 98).

Em audiência una foi ouvida a vítima e interrogado o réu.

Em debates orais, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provada autoria e materialidade delitiva. Pleiteou a fixação da pena base acima do mínimo ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, com a exasperação da pena ante a reincidência do agente que deve preponderar sobre a atenuante da confissão, aumentando a pena pelas duas majorantes, fixando-se regime fechado, sem aplicação do disposto no art. 44 do CP, nem do recurso em liberdade.

Já o d. Defensor Público pretendeu a absolvição do acusado ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, com a atenuante da confissão a ser compensada com a agravante da reincidência, afastando-se a majorante do emprego de arma de fogo, não apreendida nem periciada e porque o comparsa do réu só o aguardou do lado de fora. Ainda, requereu que a reprimenda fosse cumprida em regime diverso do fechado, com a possibilidade do acusado recorrer em liberdade, até pela detração penal.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, auto de reconhecimento pessoal positivo de fl. 13, relatório de investigação e degravação de vídeo (fls. 41/46).

A autoria é inconteste.

A vítima Auricelia declarou em solo extrajudicial (fls. 11/12) que se encontrava trabalhando normalmente no posto de gasolina quando um indivíduo adentrou a loja de conveniência, onde lhe pediu cigarros e quando foi entregar, o acusado sacou uma arma e anunciou o roubo, subtraindo dinheiro e alguns cigarros, se evadindo quando viu que havia mais pessoas, subindo em uma motocicleta Honda CG preta, sem placa. Nesta oportunidade, convidada realizar o reconhecimento pessoal, após visualizar alguns indivíduos perfilados, reconheceu categoricamente e sem sombra de dúvidas o réu, quem adentrou a loja de conveniência, sacou a arma de fogo e subtraiu bens e dinheiro.

Neste sentido foram as declarações da vítima em solo judicial reiterando que o réu chegou pedindo algo e mostrou arma, a colocou na cintura de novo, e disse que era um assalto e queria o dinheiro da gaveta. Estava só com o troco do dia seguinte. Conseguiu fazer gesto para seu patrão, que chamou a polícia, mas os meliantes já tinham ido embora. Eles chegaram em dois, numa moto. O réu entrou e o outro ficou do lado de fora e ainda roubou seu amigo, levou o dinheiro que ele tinha no bolso, cem reais aproximadamente. O réu gritava e mandava passar o dinheiro e ainda pegou dois maços de cigarros. Foi chamada ao DP em menos de uma semana e reconheceu o acusado que estava com mais três rapazes numa mesma sala, e teve certeza no reconhecimento, até porque tem o vídeo. Descreveu o réu como sendo baixinho, meio branco, tem tatuagem, aparenta ter uns 25 anos no máximo. Reconhece o réu como sendo o de numero 1.

O indiciado não apresentou sua versão em sede policial.

Sob o crivo do contraditório o réu alegou que na data e hora subtraiu porque sua esposa estava grávida, com três alugueres atrasados, e daí um conhecido fez uma proposta para roubarem comum simulacro, e chegando lá acabou subtraindo porque não estava conseguindo emprego, e ficou desesperado e acabou ficando prejudicado. Já teve duas condenações por roubo e já estava há dois anos na rua, vendendo bala no farol, mas as más companhias o levaram de volta ao crime, mas está arrependido.

Em conclusão, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito em apreço, mercê das idôneas provas coligidas, quer pela confissão judicial do réu, quer porque essa prova não é única e veio corroborada pela declaração da vítima, e pelo reconhecimento pessoal positivo feito por ela em ambas as fases, quer pelas imagens gravadas do vídeo onde se vê nitidamente a ação delituosa, as características físicas e de vestes do acusado (fls. 41/46), tudo sem prova contrária ou favoráveis ao acusado, de modo que a procedência do pedido é inarredável, assim como ocorre com a idoneidade do depoimento prestado em juízo - que é válido e eficaz para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura.

Inicialmente, no tocante ao crime de roubo, perscrutando os depoimentos extrajudiciais e judiciais da vítima, todos foram harmônicos e concisos ao apresentarem a dinâmica dos fatos ocorridos, o modus operandi do acusado, a forma como foi abordada sob grave ameaça sofrida mediante a apresentação da arma de fogo, subjugando-a e reduzindo qualquer esfera de defesa dos patrimônios do estabelecimento.

A declaração da vítima deve ser prestigiada pelo julgador, uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, são de expressiva relevância na solução da ação penal. Se suas informações são prestadas com segurança, de forma coerente e em harmonia com as demais provas, devem ser aceitas sem restrições. E no caso dos autos, as palavras da ofendida revelaram-se plenamente verossímil, corroborada com os demais elementos probatórios, especialmente pelo vídeo juntado as fls. 06/10 e 41/46.

Ressalto que: "em se tratando de crimes patrimoniais, cometidos geralmente na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, a palavra da vítima é de suma importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto não teria ela qualquer proveito em mentir." (TJSP - Apelação Criminal nº 1500517-62.2019.8.26.0616, Relator Desembargador Alcides Malossi Júnior, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 18.08.2021).

O concurso de agentes também ficou devidamente esquadriado através das palavras da ofendida, da confissão do réu, e das imagens de fls. 06/10 e 41/46 onde se percebe o comparsa do réu o aguardando do lado externo do estabelecimento vítima, numa motocicleta, para lhe dar fuga após a subtração de bens, demonstrando claramente o prévio ajuste e conluio entre eles, bem como a clara divisão de tarefas a fim de concretizar a conduta delitiva com êxito. Assim, enquanto o réu abordava e subjugava a vítima, seu comparsa o aguardava para dar fuga e, ainda, roubou uma segunda vítima, como dito hoje pela Sra. vítima. Portanto, sem condições de afastar essa majorante como pretende a Defesa, nem havendo que se falar em participação de menor importância.

Nesse sentido, vide: O transporte dos autores do crime não configura participação de menor importância" (RJDTACrimSP, 3/78). E : "Permanecendo durante a realização do tipo na expectativa de eventual intervenção material, constituindo um reforço na execução do crime, responde como co-autor não consistindo sua conduta participação de menor importância" (RJDTACrimSP, 6/234).

No tocante à causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, a prova oral colhida em Juízo, especialmente o relato da ofendida, juntamente com a degravação das imagens da câmera de vigilância do estabelecimento (fls. 06/10 e 41/46), são suficientes para demonstrar que a ameaça foi efetivamente exercida com emprego de arma de fogo, ainda que esse objeto não tenha sido apreendido nem periciado a se constatar sua aptidão, dado que o agente efetivamente se valeu dele para gerar maior temor, maior rapidez no êxito da empreitada criminosa, sem condição da vítima reagir e, portanto, deve ser mais apenado por conta de sua escolha e facilitador. E não há que se alegar parecer se tratar de arma de brinquedo, dado o temor incutido à vítima, que era a pretensão dos agentes. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do E. STF:

"HABEAS CORPUS. ART. 157 §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. ARMA NÃO APREENDIDA. PRESCINDÍVEL APREENSÃO DA ARMA. ELEMENTOS SUFICIENTES DE CONVICÇÃO. PRECEDENTE CITADO. 1. A qualificadora de uso de arma de fogo independe da apreensão da arma, bastando, para sua incidência, que constem dos autos elementos de convicção suficientes à comprovação de tal circunstância. 2. Ordem denegada." (STF - HC 92.451/SP - 2ª T. - Rel. Min. Joaquim Barbosa - j. 09.09.2008 - DJU 06.02.2009 ) grifei;

"ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra 'in reipsa'. III - A qualificadora

do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV – Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida." (STF – HC 96.099/RS – 1ª T. (TRIBUNAL PLENO) – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – j. 04.11.2008 – DJU 05.06.2009 ) grifei.

Nesses termos, ficam rejeitados os pedidos de afastamento dessas causa de aumento de pena.

Concluindo, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime imputado na denúncia, bem como o dolo e a presença das duas majorantes. O arcabouço fático-probatório amalhado é capaz de afirmar de maneira inequívoca a responsabilidade criminal do réu, de forma que não se há falar em absolvição por insuficiência probatória. Dos elementos ponderados evidenciou-se que o réu praticou crime de roubo, majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, na forma consumada. Portanto, de rigor sua condenação. Passa-se, pois, à dosimetria das penas.

Observado o art. 59 do Código Penal, a presença de maus antecedentes (fls. 55 e 112 – condenação por roubo na 1ª Vara da Barra Funda). Ressalto que o atual entendimento exarado no Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal é no seguinte sentido: No sistema normativo brasileiro, o conceito de reincidência não se confunde com maus antecedentes. Portanto, não é possível aplicar o mesmo prazo quinquenal para os dois institutos. Cinco anos valem para apagar a reincidência, não os maus antecedentes. Assim, entendo que não é possível alargar a interpretação da reincidência de modo a incluir os maus antecedentes. E pelas consequências do crime, a perda patrimonial, quer dos valores em dinheiro, quer dos maços de cigarros, fixo em primeira fase a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 12 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do condenado.

Em segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante da multirreincidência (fls. 112/113 – Condenação por roubo na 5ª Vara Criminal de Campinas, e fls. 113/114 – condenação por roubo na 1ª Vara Criminal de Diadema), a ser compensada uma delas com a atenuante da confissão espontânea, e me valendo da segunda condenação definitiva, aumento a pena em 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 14 dias-multa.

Vide jurisprudência atual acerca do tema: Dosimetria da pena. Compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Reincidência genérica ou específica. Possibilidade. Réu multirreincidente. Compensação proporcional. Art. 61, I, do Código Penal. Readequação da tese firmada no Tema 585. "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade." (REsp 1.931.145-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 22/06/2022, DJe 24/06/2022. (Tema 585) , grifei. Em terceira fase, verificam-se presentes duas causas de aumento de pena, a do concurso de agentes e a do emprego de arma de fogo, que foi efetivamente, de maneira que deve ser observada a regra contida no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, valendo-me do maior percentual, de 2/3, dado que no presente caso não reconheço uma quantidade anormal de agentes, nem emprego de mais de uma arma de fogo ou de grosso calibre. Ademais, como visto, o comparsa do réu permaneceu do lado de fora de modo que a vítima só o notou quando da fuga, e embora o réu tenha

mostrado a arma de fogo para a vítima, não a apontou e a guardou na cintura, a justificar apenas um aumento, e o maior deles. Assim, a pena vai para 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, mais 23 dias multa. Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a quantidade da pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a gravidade delitiva, fixo o regime prisional inicial fechado. Neste sentido inclusive: "(...) Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis constitui fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo, inexistindo ilegalidade a ser sanada. Precedentes. (STJ, HC 367048/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 18/10/2016). Ademais: O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade adequado ao agente que comete delito de roubo qualificado é o fechado, diante de sua periculosidade, circunstância esta que justifica o estabelecimento do regime mais rigoroso. Esse E. Tribunal decidiu que ainda que menor e primário o agente que participa de assalto qualificado não disfarça evidente periculosidade, irrecusável ousadia e clara temibilidade, atributos que não são privilégios exclusivos de delinquentes reincidentes ou de idade mais avançada (JUTACRIMSP 91/117).

Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos nos termos do art. 44 do CP, porque ausente o requisito objetivo e porque o crime foi praticado com grave ameaça à pessoa, não sendo suficiente nem eficaz à reprovação da conduta e prevenção do crime.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, sendo incongruente soltá-lo inclusive para a segurança pública e para a conveniência da aplicação da lei penal. Ora: "(...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...)" (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto DJe. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi DJe 20.03.2013).

Reconheço a custódia cautelar do Condenado mediante decretação de prisão preventiva, sem reconhecer-lhe direito à detração penal ou à progressão de regime, tendo em vista os critérios legais objetivos e a falta de atestado de bom comportamento carcerário atualizado. Assim, deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral.

Este é o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inseri dano § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de "progressão de regime" pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Deixo de fixar valor mínimo de reparação do dano, por falta de prova cabal do quantum, bem como do exato valor deste, podendo a vítima se socorrer da via Cível à

indenização.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra JONATHAN DA SILVA, qualificado indiretamente às fls. 13/23, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal, e o faço para condena-lo à pena de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado além do pagamento de 23 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

O réu não poderá apelar em liberdade. O recomendo no cárcere em que está.

Sem condenação nas custas processuais ante assistência pela DPE.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal e certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da multa.

Comunique-se a vítima nos termos do art. 201, §2º do CPP.

Oficie-se ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA